

答复类行政解释的行政诉讼法定位 及其司法审查

金自宁^{*}

内容提要 答复类行政解释既不同于包含于具体行政处理决定之中的个案解释,亦不同于以规范性文件为载体的抽象解释,由此难以被我国现行法上对具体及抽象行政行为的司法审查制度所覆盖。当前司法实践对其处理并不一致。但是,答复类行政解释的实质内涵关乎法律问题而不是事实问题,从而不宜被列为“证据”;同时,将之归为“依据”也与我国现行法及其法理不合。鉴于答复类行政解释对裁判结果的实际影响,有必要保障诉讼当事人对其提出异议的机会,为此,可以将其列为“其他诉讼材料”。法院应当在对答复类行政解释进行审查的前提下,认定其合法性和说服力。其中,合法性主要涉及解释主体权限和解释内容合法;说服力则涉及解释者的制度角色、解释程序及解释理由等因素。

关键词 答复类行政解释 司法审查 行政专长 正当程序

目 次

- 一、引言
- 二、答复类行政解释的司法实践难题
- 三、答复类行政解释的诉讼法定位
- 四、答复类行政解释的司法审查
- 五、结语

^{*} 北京大学法学院研究员。本文系 2020 年度国家社科基金重大项目“完善生态环境保护执法与司法衔接机制研究”(项目批准号:20ZDA090)的阶段性成果。

一、引言

法律有限而现实无穷无尽,将抽象的规范适用到具体的现实离不开法律解释,行政机关的执法活动也必然伴随着对所适用之法律规范的解释。20 世纪以来,“行政国家”的兴起成为不可阻挡的趋势^①,行政解释的应用范围也随之扩张。同时,如环境保护、食品药品监管、人工智能应用等领域高度复杂和专门化的行政事务越来越多,凸显了行政专长的的重要性,行政解释也随之越来越受倚重^②。

学理上根据存在形式将行政解释分为抽象解释和具体解释两类^③。其中抽象解释,指行政机关并不针对特定个案的法律适用,而是以发布一般规定的方式对法律规范的含义予以解释说明;具体解释(亦称个案解释),是指行政机关在将一般法律规范适用于个案具体事实时对法律规范含义进行解释说明。前者通常表现为规范性文件,后者则通常包含于具体行政处理决定之中。但是,在一般规定和个别行政处理决定之外,还存在其他形式的行政解释,如答复类行政解释,即本文的研究对象。由于学界对答复类行政解释关注和研究过少^④,甚至尚不存在约定俗成的名称,因此有必要先予界定。

笔者所研究的答复类行政解释,指的是特定行政机关应法院、其他行政机关或公民、法人、其他组织等不同主体以咨询、请示或询问等形式发出的请求,以“答复”“批复”“复函”等形式进行的相关法律规范解释。虽然实质内容都是说明一般法律规范的含义,但这类行政解释的存在形式,一方面具有独立于具体行政处理决定的载体(即行政函件),因而有别于包含于具体行政处理决定之中的个案解释;另一方面专门针对特定对象(即请求解释者)发出,因而不同于面向不特定对象的抽象解释。

观察我国司法实践,可以发现大量答复类行政解释已进入行政诉讼过程。^⑤诉讼双方当事人均会向法院提交这类行政解释以支持自己的主张。例如,“罗文斌等诉湘潭县环境保护局案”^⑥(以下简称“罗文斌案”)中一审原告方提交的环保部门对公民个人的复函、“桦甸市公吉乡金良养猪场诉桦甸市环境保护局案”^⑦(以下简称“金良养猪场案”)中行政主体一方提交的环保部门对下级机关的复函,均成为案件争点。并且,裁判

① See Edward L. Rubin, *Law and Legislation in the Administrative State*, Columbia Law Review, Vol.89:369, p.369-426 (1989).

② See Jerry L. Mashaw, *Between Facts and Norms: Agency Statutory Interpretation as an Autonomous Enterprise*, University of Toronto Law Journal, Vol.55:497, p.497-534 (2005).

③ 参见彭霞:《走向司法审查:行政解释的困境与出路》,载《政治与法律》2018 年第 10 期,第 71-79 页;李洪雷:《行政法的适用与解释初论》,载葛洪义主编:《法律方法与法律思维》(第 8 辑),法律出版社 2012 年版,第 3-26 页;高秦伟:《行政规范解释论》,中国人民大学出版社 2008 年版,第 50 页。

④ 在笔者有限检索范围里,我国法学界已发表成果中为数不多强调答复类行政解释不同于抽象解释和个案解释有其特殊性的文献,参见高秦伟:《论其他形式的行政规范解释》,载《当代法学》2008 年第 5 期,第 61-66 页。

⑤ 这种现象并不限于行政诉讼,只是本文选择以行政诉讼为论域,并不就民事和刑事诉讼中的答复类行政解释展开专门讨论。

⑥ 参见湖南省湘潭市中级人民法院(2017)湘 03 行再 19 号行政判决书。

⑦ 参见吉林省桦甸市人民法院(2016)吉 0282 行初 27 号行政判决书。

法院在诉讼中也会主动致函主管行政机关寻求行政解释。例如,最高人民法院 2018 年发布的典型案例“孙桂花诉原浙江省环境保护厅环保行政许可案”(以下简称“孙桂花案”)中有如下说明:“原环保部制定的《机动车环保检验合格标志管理规定》专业性和政策性较强,为更好地理解该文件的制定目的、依据及出台背景等,法院向原环保部发函了解情况,原环保部复函详细作了介绍”^⑧。在这些案件中,裁判者均无法回避对答复类行政解释的处理。质言之,答复类行政解释相关的法律问题在司法实践中已是无可回避的存在,亟需学界的关注和研究。

答复类行政解释在我国各行政执法领域均不乏实例。^⑨笔者选择在环保行政诉讼领域搜寻相关典型实例,主要考虑是:一方面,环境保护作为新兴法领域,相关立法数量繁多且变动迅速,通过法律解释澄清法规含义、解决法条含糊矛盾所造成的疑问以适应现实的需求较为突出。与此相应,此领域内各种类型的行政解释数量较多,出现了大量可供观察分析的司法实例。另一方面,行政解释之所以在现代行政国家有了长足发展,在很大程度上是因为现代社会是专业分工的社会,行政机关在相关领域里的专长使得行政解释具有显著价值;而环境保护也是一个专业性较强的领域,在这个意义上,环保行政诉讼案件具有典型性。

二、答复类行政解释的司法实践难题

答复类行政解释虽然被诉讼当事人或法院广泛运用于个案纠纷的解决之中,但在现有司法实践中,法院对这些行政解释的处理存在诸多含糊和冲突之处。最明显的是,不同裁判对这些函件的法律定位不一。

在多数案件中,法院采取了两种迥异的处理方法:一种是将载明答复类行政解释的函件列为“证据”;另一种是将这些函件列为行政机关作出被诉行政行为的“依据”。例如,同样是《环境保护部办公厅关于高污染燃料禁燃区管理中直接燃用生物质等问题的复函》(环办大气函〔2017〕1886号),在“霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司诉霍邱县环境保护局环境行政处罚案”^⑩中,原告(行政相对人)将之列为“证据材料”,法院在裁判文书中写明了这一点但未作更多评论,相当于默认了此定性;在“重庆画木木制品有限公司诉重庆市沙坪坝区人民政府、重庆市沙坪坝区环境行政执法支队案”^⑪(以下简称“画木木公司案”)中,被告(行政主体)将之列为“依据”,法院在裁判文书中对此亦无异议。

⑧ 《行政诉讼附带审查规范性文件典型案例》,载最高人民法院官网, <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-125871.html>, 2022 年 12 月 1 日访问。

⑨ 在政府各部门官网上可检索到相关信息。例如,《关于对〈中华人民共和国学位条例〉等有关法规、规定解释的复函》,载教育部官网, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/200311/t20031121_61707.html, 2022 年 12 月 1 日访问。

⑩ 参见安徽省安中市中级人民法院(2017)皖 15 行终 133 号行政判决书。

⑪ 参见重庆市渝北区人民法院(2018)渝 0112 行初 488 号行政判决书。

这些不同的表述并不仅仅是语词而已,而是对应着诉讼法上的不同定位,而不同的法律定位又对应着既定法上不同的规范要求:按照我国现行诉讼法规定,若这些函件被归类为证据,则应由法院在质证基础上予以审查认定;若不被归类为证据,则诉讼法上的证据质证、审查和认定规则均不适用。也正因此,在司法实践中,有时法院会直接裁定当事人对这些函件的法律定性错误。如,在“金得来公司诉偃师环保局案”^⑫(以下简称“金得来公司案”)中,被告将环境保护部关于《环境保护法》(2014年修订)第61条适用有关问题的复函(环政法函〔2016〕6号)列为“证据1”,原告在质证时对其“真实性无异议”,而法院经审查后却认为“被告提交的证据1、2、3、4、5系法律、法规或规范性文件,不属于法律规定的证据种类形式,不予认证”。

在有些案件中,法院在裁判时并不指明这些函件在诉讼法上的定位,只在裁判文书的说理论证中直接将以这些函件为载体的行政解释“予以采纳”。如,在“林静诉苏州国家高新技术产业开发区环境保护局案”^⑬(以下简称“林静案”)中,法院在裁判文书中称曾致函原环保部并收到“复函”(环办政法函〔2016〕2167号),在该复函中原环保部“明确作出解释”,而“环保部作为对该名录依法享有解释权的机关,其答复意见本院予以采纳”。

站在诉讼当事人立场上,比起将这些函件列为证据还是依据,更重要的是法院对这些答复类行政解释是否接纳的实质立场。毕竟,只有法院允许答复类行政解释起作用、使之在诉讼过程中具有一定的权重,当事人才会有将这些函件提交到法院的动力。目前,法院一般不会否定这类函件在诉讼中发挥作用。这主要表现为,在这些答复类函件被当事人作为“证据”或“依据”提交时,法院通常会接收,即允许这些材料进入诉讼过程之中^⑭。而法院也会主动咨询行政机关^⑮,即表明法院是明确欢迎这类函件发挥作用的。

当然,最终能表明法院实质态度的,还是法院在裁判意见中是否“采纳”了这类函件中所包含的行政解释;若是法院在哪怕只是部分案件中对这类函件表现出了高度尊重,也会极大地激发诉讼当事人向法院提交这类函件的积极性。观察我国司法实践,可以发现法院的确在许多案件中采纳了案涉答复类行政解释,并整体上对其持尊重态度^⑯,只是在同样“采纳”了答复类行政解释的不同案件中,法院显示出的尊重程度存在一定差异。如,比较前述“林静案”和“画木木公司案”,可以发现法院对答复类行政解释的尊重程度在后案中超过了前案。在“林静案”中,法院在采纳原环保部复函中的行政解

⑫ 参见河南省洛阳铁路运输法院(2018)豫7102行初126号行政判决书。

⑬ 参见江苏省苏州市姑苏区人民法院(2016)苏0508行初63号行政判决书。

⑭ 虽然像“金得来公司案”那样“不予认定”的实例也存在,但其裁判说理中法院的“拒绝”是基于具体特殊理由,并不属于一般地排除全部这类材料进入诉讼的情形。

⑮ 检索相关司法裁判文书发现,法院在诉讼中主动致函咨询行政机关的情形也有不载明于裁判文书的,如“孙桂花案”的原裁判文书中就未提及法院曾向原环保部咨询并取得复函。参见杭州市西湖区人民法院(2015)杭西行初字第291号行政判决书。

⑯ 例如,笔者通过“北大法宝”数据库中“法宝联想”项下的“案例引用”功能,检索到引用2015年以来发布的18份环保复函的123个司法案例中,法院裁判不采纳所涉环保复函的只有2个。(检索时间:2021年11月1日)

释之前,先对解释主体即原环保部是否具有解释权限作了审查认定。而在“画木木公司案”中,法院则在未对案涉复函作任何审查的情况下,直接在“本院认为”部分以援引和适用法律法规相类似的方式援引和适用了该复函。至于为何存在这样的差别对待,裁判文书中并未见到相关说理,因而,这对于那些试图在类案中寻求规范指引的人而言,确会令人困惑。

综上,答复类行政解释相关司法实践所提出的问题至少有二:第一,答复类行政解释在诉讼法上究竟应如何定位?它到底应被列为证据、依据还是其他诉讼材料?第二,法院应如何对待答复类行政解释?特别是,在法院裁判中,它应有多大权重?这种权重与哪些因素相关?对此,现行法上并无明确的规范指引,学理上亦无现成的教义供给,而司法实践中上述矛盾或含糊的处理方式,不仅令个案当事人无所适从,也会有损司法权威和稳定。

三、答复类行政解释的诉讼法定位

当前我国司法实践中对答复类行政解释的运用主要存在三种不同的处理方式,以下逐一予以讨论。

(一) 答复类行政解释不应被列为“证据”

我国三大诉讼法对诉讼证据相关规则均有专章规定,但只有《刑事诉讼法》对证据概念本身作出了界定,即:“可以用于证明案件事实的材料,都是证据”。就学理而言,研究者尽管对证据的界定表述各有差异^{①⑦},但存在明显的交叉共识,即证据应与诉讼个案中的待证事实具有相关性,且证据在诉讼中的基本功能是服务于案件事实的认定。而所有行政解释,包括抽象解释、具体解释和笔者所研究的答复类行政解释,就其实质内容而言,是对一般法律规范的解释;就其在诉讼中的功能而言,能够帮助解决的,只是应然的规范含义澄清问题,而不是实然的事实认定问题。因此,以行政函件为载体的答复类行政解释不应被归类为证据。

那么,为什么司法实践中仍有如此多的案例将答复类行政解释归类为证据呢?通过对相关裁判文书的分析,可以发现至少有以下两点易致混淆。

一是与答复类行政解释的表现形式相关。如前所述,答复类行政解释的表现形式,往往是“复函”“批复”等行政公文。按照我国《党政机关公文处理工作条例》的规定,“批复”适用于“答复下级机关请示事项”,“函”适用于“不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项”。^{①⑧}行政机关不仅可用这些形式的公文载明相关行政解释,也可用这些形式的公文处理其他公务,包括澄清特定事实等。当行政机

^{①⑦} 参见陈瑞华:《刑事证据法》(第3版),北京大学出版社2019年版,第85-94页;江伟主编:《民事诉讼法学》(第2版),北京大学出版社2014年版,第179-181页。

^{①⑧} 参见《党政机关公文处理工作条例》第8条。

关以这类公文形式澄清特定事实并由此对查明诉讼中的个案事实有帮助时,就完全可以将这些行政公文列入证据。例如,在“张小燕等诉江苏省环境保护厅案”^{①⑨}(以下简称“张小燕案”)中,被告提交当地文物局的复函^{②⑩}作为公文书证证明案涉双井变电站并非文物保护单位。在这种特定的情况下,案涉行政公文的内容并非行政解释,因而并不属于答复类行政解释。换句话说,行政公文应用广泛,既可以作答复类行政解释的载体,也可以作其他内容的载体,不应将它们混同对待。

二是源于事实与规范的区分本身的复杂性。虽然“事实及法律问题的区分贯穿于整个诉讼法”^④,但就实践而言,法律适用活动就是在事实与规范之间“相互穿透”、不断“往返流转”的动态过程^⑤。所谓的“事实认定”,无法离开对法规范的理解和解释而独立进行,因为这里的重点在于对区别于自然事实的“法律事实”的认定,即那些与法律规范规定无关的事实最终会被排除出去,只留下从既有规范来看仍具相关性的事实。至于所谓的“找法”,即确定可适用于手头个案的法规范,也不是能脱离个案事实认定的、“纯粹的”法律解释过程,因为一般法规范的含义往往是在遭遇特定案件事实时才得以具体化和精确化的。正是在这个意义上,法律问题和事实问题的区分“并不排除这样一个过程,即在将特定事实涵摄于某一大前提之前,仍然需要借助该特定事实状态对待适用的大前提加以衡量、并使之精确化”^⑥。具体到司法运作过程中,法律和事实问题发生交叉重叠的一个典型情形是,当争点并非特定规范“作何理解”,而是特定规范“是否存在”“是否已生效/失效”时,虽然看起来当事人仍在争论法律问题,但该争点在可理解的意义上也可被归为“事实”问题。只是,此种“事实”并非前述法定证据制度所指向的“个案事实”。

然而,规范与事实在法律实践中不可避免会发生的上述交叉重叠现象,并不意味着对事实问题与规范区分本身的否定。这不仅仅因为事实与规范的区分在理论上是可能的,也因为这一区分已经被我国行政诉讼法上区分事实认定和法律适用的规定^⑦及相关的学理观点^⑧所明确接受。由此,这一区分在我国行政诉讼中具有重要的制度意涵和现实意义。一旦错置,带来的不仅仅是概念上混淆^⑨,也会给诉讼当事人造成实际困扰,甚至带来不利影响。

①⑨ 参见江苏省高级人民法院(2015)苏环行终字第00002号行政判决书。

②⑩ 参见《〈关于110千伏双井变电站是否位于文物保护范围的咨询函〉的复函》(镇江市文物局镇文物函〔2015〕9号)。

④ [德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2004年版,第186页。

⑤ 参见前注④,卡尔·拉伦茨书,第162-163页。

⑥ [德]齐佩利乌斯:《法学方法论》,金振豹译,法律出版社2009年版,第132-133页。

⑦ 参见《行政诉讼法》第5、69、70、89条等相关规定。

⑧ 通行的教材一般设独立章节分别讨论行政诉讼中的证据问题和法律适用问题。参见姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》(第7版),北京大学出版社、高等教育出版社2019年版,第461-482,508-520页;应松年主编:《行政法与行政诉讼法学》,法律出版社2005年版,第495-512页。

⑨ 参见赵清林、杨小斌:《规范性文件依据也是行政诉讼证据——兼与甘雯先生商榷》,载《行政法学研究》2002年第3期,第60-64页。

以“金良养猪场案”^{②7}为例。该案中,行政主体将《环保部关于逃避监管违法排污情形认定有关问题的复函》列为“证据”,相对人在质证时,对其“真实性”无异议,但质疑“这只是一个复函,不是法律法规也不是部门规章,不能作为认定事实的法律依据”。虽然这一质疑已经超出了一般证据质证的范围(即证据三性),但当事人认为有必要表达出此种意见,表明其作为利害关系人并没有被“证据”这一标签所迷惑,没有错认这一复函在该起诉讼中的真实功能。换句话说,虽然该案中行政主体方声称援引该函意在证明相对人违法的特定事实(违法排污),但实际上该函并不能证明相对人“排污行为”作为客观事实是否发生,也即并不能帮助解决实然的“事实问题”。该函真正支持的是行政机关将相对人的排污活动认定为“违法”排污,而相对人行为是否“违法”属于典型的法律问题。此案当事人对案涉行政函件的上述质疑被法庭允许并且记录在案,由此该质疑有机会在裁判中被考量,说明法院在处理此案时亦未被“证据”这一错误的标签所迷惑。但是,假如当事人或裁判法院真的将之当成“证据”并严格遵循现行诉讼法和证据法相关规定予以处理,相对人就可能丧失在诉讼中提出上述异议的机会。

(二) 答复类行政解释不宜被列为“依据”

答复类行政解释是否可归入“依据”,涉及如何理解我国现行法上的“依据”问题。我国《行政诉讼法》第63条和第67条均提及了“依据”,但二者涵义不同,分述如下。

1. 《行政诉讼法》第63条中区别于“参照”的“依据”

《行政诉讼法》第63条第1款规定:“人民法院审理行政案件,以法律和行政法规、地方性法规为依据。”第3款规定:“人民法院审理行政案件,参照规章。”据此,我国实在法明确区分了“依据”和“参照”。学理上一般认为,此处的“参照”规章意味着,“从总体上说,(规章)对人民法院不具有拘束力,对不符合或不完全符合法律、法规的规章,人民法院有灵活处理、拒绝适用的权力”^{②8},这也被称作是一种“有条件的适用”;而与“参照”形成对照的“依据”,则是指法律、行政法规和地方性法规这三类规范性文件的规定对法院具有普遍约束力,法院在审理行政诉讼案件时并不能拒绝适用,这也被称为“无条件适用”^{②9}。

然而,此条将“依据”的范围明确为三种,即法律、行政法规和地方性法规。而答复类行政解释,从制定主体来说,明显无法归入法律和地方性法规。至于答复类行政解释若由国务院制作,是否可能归为“行政法规”从而成为此条所谓“依据”?这一问题在2001年《行政法规制定条例》出台之前可能还存在一些含糊和可争议的空间,但在

^{②7} 参见前注⑦,吉林省桦甸市人民法院(2016)吉0282行初27号行政判决书。

^{②8} 前注②5,姜明安主编书,第512-513页。

^{②9} 前注②5,应松年主编书,第510-511页。不过这一点并非没有争议,参见章剑生:《依法审判中的“行政法规”——以〈行政诉讼法〉第52条第1句为分析对象》,载《华东政法大学学报》2012年第2期,第124-132页。

2002年《行政法规制定程序条例》生效后,仅就名称^{③①}和公布^{③②}等形式要求^{③③}来看,就可知答复类行政解释并不是行政法规。

综上,《行政诉讼法》第63条并不能为将答复类行政解释归类为“依据”的司法实践提供支持。

2.《行政诉讼法》第34条中区别于“证据”的“依据”

观察那些将答复类行政解释列入“依据”的裁判文书,可以发现这些答复类行政解释大多是行政诉讼被告在提交证据时一并提交给法庭的。这一做法的直接法条依据应是《行政诉讼法》第34条第1款的规定,即:“被告对作出的行政行为负有举证责任,应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件”。此条规定将“证据”和“依据”并列,明确要求行政诉讼被告应当同时提供二者。

需要说明的是,根据一般诉讼法理,法律规范的查明通常被认为属于司法认知的范围,并不需要当事人提交材料予以证明^{③④}。与此相应,我国《民事诉讼法》和《刑事诉讼法》均未提及诉讼当事人一方有义务提交其主张所依据的规范性文件。而《行政诉讼法》要求被告提供其作出行政行为“所依据的规范性文件”,只能解释为基于特殊政策考虑^{③⑤}而作出的例外安排。

据《行政诉讼法》第34条得出答复类行政解释属于所谓的“依据”之前,由于此条规定将作出行政行为的“依据”明确限定为“规范性文件”,于是存在一个无法回避的问题,即答复类行政解释属于规范性文件吗?以行政机关为制定主体的规范性文件包括行政法规、行政规章和其他行政规范性文件。由于上文已经分析过,国务院以答复形式作出的答复类行政解释并不是行政法规。而对照《规章制定程序条例》(2017年修订)可以确认,答复类行政解释的名称、制作程序以及发布方式均与行政规章存在明显区别。于是,问题可进一步限定为:答复类行政解释是否属于行政法规和规章之外的其他行政规范性文件呢?司法实践中很多法院在裁判中给出的答案是肯定的(如“金得来公司案”),也有一些研究者支持这样的定位^{③⑥}。然而,答复类行政解释既不同于抽象解释也不同于个案解释的“另类”特性,与其他行政规范性文件相关学理仍有圆凿方枘之嫌。

③① 《行政法规制定程序条例》第5条第1款规定:行政法规的名称一般称“条例”,也可以称“规定”、“办法”等。国务院根据全国人民代表大会及其常务委员会的授权决定制定的行政法规,称“暂行条例”或者“暂行规定”。

③② 《行政法规制定程序条例》第28条第1款规定:行政法规签署公布后,及时在国务院公报和中国政府法制信息网以及在全国范围内发行的报纸上刊载。国务院法制机构应当及时汇编出版行政法规的国家正式版本。

③③ 《行政法规制定程序条例》对立项、起草、审查和决定公布均有专节规定。

③④ 参见叶自强:《司法认知论》,载《法学研究》1996年第4期,第22-36页。

③⑤ 例如,我国多级立法体制下,行政行为所依据的法律规范来源复杂广泛,全部交由法院查明任务艰巨,而行政机关作为执法者对其作出的行政行为所依据的规范理当知悉。

③⑥ 参见李宝悦:《部门批复的行政解释权于行政审判中的效力问题研究》,载《全国法院系统第二十二届学术讨论会论文集》2011年,第1167-1182页。

其他行政规范性文件^{③⑥}指的是行政机关制定、发布的“具有普遍约束力的决定、命令”^{③⑦}。司法实践中广泛采用的认定标准有二：一是针对不特定对象发布；二是能反复适用^{③⑧}。而答复类行政解释，尽管就其实质内容而言，属于对一般规范的解释，由此不可避免会涉及针对不特定对象、可反复适用的内容，但其特殊性在于，从外在形式上看，它们均是针对特定对象（即询问者）而发出的，并不满足“针对不特定对象发布”这一标准^{③⑨}，这一点较少有疑义。至于答复类行政解释能否“反复适用”，则仍有推敲余地。实践中，以函件形式请求行政机关作出解释，特别是下级行政机关向上级行政机关以“请示”方式寻求答复的，大多并非出于对一般法律规范本身应当如何解释的兴趣，而是因具体个案情形中的疑难而触发；而行政机关以复函等公文形式所作答复也大多属于“一事一议”^{④⑩}，“就事论事”针对性强，若主张此种答复可以超出特定个案情形适用尚需特别论证。如，在“罗文斌案”中，再审被申请人就质疑再审申请人所提交的原环保部环评司复函的“对象是针对吴安心，并非（本案中的）华绿公司复混肥分公司复合肥生产线的行政许可案件”，而法院在“本院认为”部分否定了该复函的关联性，理由之一正是采纳了这一答辩意见。

与答复类行政解释“一事一议”的特点一致，实践中的答复类行政解释只有部分通过正式（如政府官网）或非正式的途径向一般公众公开过，更多的甚至并未“抄送”请求解释者之外的其他主体。由此，若将答复类行政解释归入其他规范性文件，一个无法回避的问题就是：未经公布的情况下，它们能否产生“普遍约束力”？在最低限度的交叉共识上，行政主体作出对相对人不利的决定时所依据的规范应当是事前公开发布过的。^{④⑪}而且，虽然我国尚未对其他行政规范性文件的制定程序作出统一规定，但从行政法规和规章制度程序的要求^{④⑫}来看，均应在公布一段时间后才开始施行；确有必要的，才允许自公布之日起施行；举重以明轻，比法律法规和规章效力层级更低的其他行政规范性文件，也应推定未经公布即不生效。

更进一步说，根据《行政诉讼法》第53条规定，被诉行政行为所依据的行政法规和规章之外的行政规范性文件属于相对人可以“一并”请求法院审查的对象。而从行政诉讼实务中看，“未履行法定的批准或公开发布程序”也被列为法院认定附带审查的规范性文件“不合法”的理由之一^{④⑬}。据此，若将答复类行政解释视同其他行政规范性文件，

③⑥ 亦有研究者称之为行政规定或行政规则。参见朱芒：《论行政规定的性质——从行政规范体系角度的定位》，载《中国法学》2003年第1期，第33-47页；沈岿：《解析行政规则对司法的约束力——以行政诉讼为论域》，载《中外法学》2006年第2期，第170-185页。

③⑦ 《中华人民共和国行政诉讼法》第13条第2款。

③⑧ 参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第2条第2款。

③⑨ 就此而言，前述为数不多的、专门研究函复类行政解释的一些成果将之归类为“其他规范性文件”是不准确的。

④⑩ 《党政机关公文处理工作条例》第15条明确规定“请示应当一文一事”。

④⑪ 《行政处罚法》（2021年修订）第5条第3款：对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

④⑫ 《行政法规制定程序条例》（2017年修订）第29条，《规章制度程序条例》（2017年修订）第32条。

④⑬ 参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第148条第2款第4项。

相当于排除了所有“未公开发布过”的答复类行政解释在行政诉讼中可能的作用,包括法院在诉讼中主动致函行政机关而获得的答复。若不将答复类行政解释混同于其他规范性文件,原本不必对其在行政诉讼中的应用作如此严格的限制。

(三) 答复类行政解释可被列为“其他诉讼材料”

如前所述,无论将答复类行政解释列为“证据”还是“依据”,均存在窒碍难通之处。那么,实践中的第三种做法,即回避指明其性质,直接在说理时将之引为论据,是否妥当呢?

初看起来,法院在“本院认为”部分将答复类行政解释引为论据,似乎并无不妥。如,在前述“画木木公司案”中,判决在“本院认为”部分直接援引生态环境部复函,以支持对相关法规(《重庆市大气污染防治条例》第32条第2款)和规章(《高污染燃料目录》)的解释,并据之认定案涉“木柴”属于高污染生物质燃料,看上去逻辑清晰论证有力。但是,如果将视线从已凝固为“静态”的裁判文书上移开,转而将作为“动态”实践的诉讼过程纳入视野,并将此种处理方式与前述将之列为证据和依据的处理方式作一整体比较,可发现此种处理方式的缺陷:在那些将答复类行政解释列为证据或依据的案件中,当事人在诉讼过程中(如质证阶段或辩论阶段)有机会对之发表异议;但是,如果这类解释只在法院裁判阶段才出现,则当事人并无机对之发表异议——这明显有违程序正义理念。考虑到它们在事实上已经出现于诉讼过程中,受到裁判者的尊重,由此对裁判结果可能发生实质性影响,将之明确列出以保障双方当事人均有机会对之发表意见,是更为公平公正的处理方式。

理论上,有不同路径可以实现对当事人发表意见机会的保障。最直截了当的是立法路径,即修订现行法律,对答复类行政解释作出明确规定。但法律修订需要形成充分共识并且通过相对繁琐的立法程序。可能的替代选项是司法先行探索的路径,即在立法修订之前由法院充分运用司法裁量权,在个案中先积累经验,逐渐形成共识。就后一路径而言,理论上又存在不同的具体操作方式。例如,可以考虑扩张解释我国现行法上“其他诉讼材料”^④的相关规定将答复类行政解释包括在内。实际上,在传统的“证据”和“依据”之外新增“其他诉讼材料”这一类别确有必要。不仅答复类行政解释,还有我国诉讼实务中发挥着重要作用的“法律专家意见”^⑤、“案例引证报告”^⑥等,均有类似的(既非证据亦非依据的)归类难题。即这些材料并无法定拘束力,但由于专业性和权威性而通常会对法院裁判具有一定的实际影响力,即使那些对其持批评立场的评论者,也不能不承认它们在诉讼中具有“信息提供”^⑦的积极功能;若不将它们作为诉讼材料明确列

④ 如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第79条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第241条均提到了“其他诉讼材料”。

⑤ 浙江省高级人民法院研究室:《“专家法律意见书”对审判工作的影响》,载《法律适用》2003年第10期,第34-37页。

⑥ 孙艳、洪碧蓉:《案例引证制度之观察——以东莞市第一人民法院的规定为对象》,载《电子知识产权》2015年第8期,第45-49页。

⑦ 参见项焱、海静:《“法庭之友”:一种诉讼信息披露机制》,载《法制与社会发展》2017年第2期,第145-164页。

出,使其逃脱当事人之间的对质和辩论的话,法院对它们的运用就很难避免任意、专断甚至滥用的指责。

当然,不同于对答复类行政解释作出明确规定,将其归入“其他诉讼材料”只是在并无更好替代选项的情况下、最大限度尊重现行法的一个方便标签。因为作为证据和依据之外的“其他诉讼材料”,在我国现行法上并不存在一整套对应的处理机制和规范要求,在当前行政诉讼法理上也并不存在现成的教义;而且,由于法规范有限而现实无穷无尽,作为无法提前列举穷尽的各种诉讼材料之“兜底筐”,即使在未来也不太可能形成(像证据规则那样)统一适用的规则和教义。由此,将答复类行政解释归入“其他诉讼材料”,其作用限于标记出它具有不同于证据和依据的特性,并且强调它应当以公开列明的方式进入司法程序接受当事人质疑。至于在保证当事人对答复类行政解释有发表异议的机会后,裁判法院应当如何对待它们,还需进一步展开讨论。

四、答复类行政解释的司法审查

法院主动咨询或允许诉讼当事人提交答复类行政解释,并不意味着法院应当对该行政解释的内容“照单全收”。虽然《行政法规制定程序条例》第31条规定“行政法规的解释与行政法规具有同等效力”,《规章制定程序条例》第33条规定“规章的解释同规章具有同等效力”,但此两条规定指的是法规或规章制定者以法规或规章为形式的抽象解释。在此明确规定之外的各种行政解释,法理上一般认为,对“行政机关本身有拘束力”,但法院则“不受之拘束”。^{④8}我国长期以来在司法实践中也有此种认识,如,最高人民法院曾指出,“有关部门为指导法律执行或者实施行政措施而作出的解释”并“不是正式的法律渊源,对人民法院不具有法律规范意义上的约束力”;只是,法院经审查认为其“合法、有效并合理、适当的”,应予承认;法院并可在裁判理由中就其“是否合法、有效、合理或适当进行评述”。^{④9}因此,对进入诉讼程序的答复类行政解释,裁判法院有权、也应当对其进行审查。

(一) 答复类行政解释的合法性

我国现行法尚未对答复类行政解释作出明确的专门规定,但是,作为一种行政活动,答复类行政解释依然受行政法治原则的约束。法院在诉讼中给予答复类行政解释适当尊重之前,应当依据行政法治原则及相关法理,确认案涉行政答复是否满足权限合法和内容合法的要求。

1. 权限合法

从实在法来看,行政解释与立法解释和司法解释并立,是我国多元法律解释体制的

^{④8} 参见前注^{②5},姜明安主编书,第64页。

^{④9} 参见最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》(法〔2004〕96号)。

重要组成部分之一。^{⑤①}我国国务院及其主管部门进行抽象解释,有明确的授权来源。^{⑤②}另外,行政法规、行政规章或其他行政规范性文件中有时也会明确由特定行政机关“负责解释”。^{⑤③}但是,我国现行法上,对抽象形式之外的行政解释,即具体行政解释和答复类行政解释主体权限,并无明确规定。

这就引出一个疑问:在现行法并无明确专门规定的情况下,行政机关是否享有法律规范解释权?从法理上分析,法律规范需经解释始可适用,离开了对所执行法律规范的解释,行政执法机关的执法活动根本不可能实现。在这个意义上的确可以说,“法律解释权天然属于法律实施者”^{⑤④},行政机关以各种形式作出行政解释的权力是行政执法权不可分割的一部分;只要法律赋予了行政机关特定领域或特定事务的法律执行权,该行政机关则同时享有对所执行法律规范的解释权。

在此基础上,可进一步理解行政机关为何采取复函等“另类”解释形式。首先,行政系统以“层级节制”方式组织运作,上级行政机关对下级行政机关的执法活动负有监督指导之责,因此,若下级行政机关就执法中遇到的法律疑难请示上级,上级行政机关理当依其职责作出指示。其次,行政执法活动直接涉及公民、法人和其他组织的权利义务,明确既定法律规范要求有利于公众有效地安排自己的生活计划,故对公众提出的与执法活动相关的疑问,行政机关亦有责任在其职权范围内予以解答。最后,现代司法处理争议所需进行的事实认定和法规范解释大量涉及各种专门知识应用,当这些问题被认为是行政机关的专长时,诉讼当事人和法官自然就会转向行政机关,而行政机关理当在其职权范围内提供可能的帮助。

至于我国法律的解释权属于全国人民代表大会常务委员会、行政法规由国务院解释、规章由规章制定机关解释等解释权“专属”特定主体等规定,分别指的是有权机关以相当于法律、行政法规和规章的形式作出抽象解释,并不排除行政机关以抽象解释之外的形式(即具体解释和答复类解释)对所执行法规范进行解释。

需要注意的是,从同一法理也可推论出,行政执法机关所享有的、并非法有明文授权的答复类行政解释权从属于行政执法权,因此,不应超越特定行政机关法定的行政执法权限。具体而言,这要求答复类行政解释所解释的对象,应该只针对行政机关依法应当予以执行的法律规范。对超出其执法范围的法律规范作出的解释,属于无权解释,相当于路人甲对法律规范应如何理解所作的评论,并不享有行政机关作为国家法定执法主体这一既定制度角色所赋予的权威。

同时,无论何种形式的行政解释,其内容均应是对既定法律规范含义的阐明,由此被

⑤① 参见张志铭:《关于中国法律解释体制的思考》,载《中国社会科学》1997年第2期,第99-116页。

⑤② 《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律解释工作的决议》第3条:“不属于审判和检察工作中的其他法律、法令如何具体应用的问题,由国务院及主管部门进行解释。”

⑤③ 如《建设项目环境影响后评价管理办法》第14条、《突发环境事件应急管理办法》第39条均规定由国务院环保行政主管部门负责解释。

⑤④ 陈金钊:《法律解释的意义及其对法治理论的影响》,载《法律科学》1999年第2期,第3-10页。

限定在既定法条可能意义的范围之内,不能超出此范围创设新的权利义务规范。这意味着:第一,“在文义明确时,(文义解释之外的)其他解释方法将不再适用”;第二,当“法律文本框架里存在多种解释的可能性”时,解释者也不可以任性任意而为,而应当在可能的空间内寻求最为妥切的解释^{⑤4}或说“可理性证立”的解释^{⑤5}。若解释者超出法律解释的正当界限作出了新的权利义务安排,则不再是对既定法的“解释”而已经成为新的“立法”,亦属超越权限。

2. 内容合法

法院应对答复类行政解释进行内容合法性审查,对于内容违法的应予排除。答复类行政解释内容不合法的情形,既包括法体系和法原则的违反(如与现行有效的法规范相抵触、违法地增加公民、法人和其他组织的义务或扩大行政权力等),也包括解释方法的误用或滥用(如与法条文意不符、不合逻辑、违反/歪曲立法目的等)。

需要强调的是,对行政解释进行内容合法性审查并不局限于所谓的文义解释、体系解释和目的解释等常规方法,有时还需要结合政策后果^{⑤6},综合权衡公共利益和对公民、法人和其他组织的不利影响,作更进一步的实质合法性判断。例如,特定诉讼中提交到法庭的答复类行政解释可能背离行政实践中的一贯做法或行政机关之前以各种形式作出的相关解释。如果认可这类解释,则可能有悖执法统一,违反相同情形同样处理的正义要求,还可能损及政府公信力,破坏公民、法人和其他组织的正当信赖。因此,对于因违反信赖保护原则而构成实质违法的行政解释,法院一般不应采纳。当然,信赖保护原则在适用时涉及利害权衡:当维持之前的行政解释或行政惯例对公共利益可能造成的损害远大于对公民、法人和其他组织的信赖保护时,还是应当允许行政机关在给予公民、法人和其他组织相应补偿的前提下,以新的行政解释取代原有解释和以往做法。

(二) 答复类行政解释的说服力

对行政机关在其执法权限范围内作出的、内容并不违法的答复类行政解释,虽然无法源意义上的规范拘束力,但具有一定的说服力^{⑤7}。结合司法实践及相关法理,影响答复类行政解释说服力大小的因素,应当包括与行政机关制度角色相关的行政专长、正当程序和解释理由等。

1. 解释者的制度角色和行政专长

从法理上分析,法律规范的解释原本是法院的专长,法院只在案涉争议超出自身专长时,才需要包括行政解释在内的各种协助。包括答复类行政解释在内的所有行政解释,

^{⑤4} 参见[德]托马斯·M.J. 默勒斯:《法学方法论》(第4版),杜志浩译,北京大学出版社2022年版,第35、41页。

^{⑤5} 参见[德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论:作为法律证立理论的理性论辩理论》,舒国滢译,商务印书馆2019年版,第33页。

^{⑤6} 这被一些研究者认为是行政解释不同于一般法律解释的特征之一。See Jerry L. Mashaw, *Norms, Practices, and the Paradox of Deference: A Preliminary Inquiry into Agency Statutory Interpretation*, *Administrative Law Review*, Vol.57:501, p.501-542 (2005).

^{⑤7} 用肖尔的话说,就是并无“拘束性”或强制性(mandatory)权威,只有说服力或选择性(optional)权威。参见[美]弗里德里克·肖尔:《像法律人那样思考:法律推理新论》,雷磊译,中国法制出版社2016年版,第79页。

之所以特别得到承认,从根本上说源于解释作出者的行政专长,即行政机关按照自己的法定制度角色在特定领域里获得的相对较多的经验、知识和技能。这种行政专长,在具体情形中可能指向非常不同的内容,如熟悉和掌握行政目标及相关政策考虑、行政执法资源的限度和分配情况、行政实践惯例、支持法规范执行的裁量基准、执法所涉多元社会利益格局及其变动情况等。

这种行政专长理应得到司法机关的尊重。但是,这不当被混淆为在涉及行政专长时,法院应当放松甚至放弃审查。因为内容涉及行政专长的答复类行政解释和不涉及行政专长的答复类行政解释一样,都可能存在不相关或不合法的情形。而要求法院尊重在事务性质上涉及行政专长、内容上却属违法的答复类行政解释是荒谬的。

行政专长的含义不宜泛化。在司法审查论域中讨论行政专长,虽然的确指向行政官员相对擅长而法官相对并不擅长的知识或技能,但需注意,不应将之误解为凡法官并不擅长的均属行政专长。法官之不擅长并不等于行政官员之擅长^{⑤8},例如自然科学技术知识应用的问题,不仅超出了普通法官的专业知识范围,也并非一般行政官员所擅长。

同样与解释者的制度角色相关的现象是,在实务中,行政机关对自己制定的规则作出的解释,相比对那些自己并非制定者的规则的解释,会受到更多尊重。这虽然被一些研究者批评^{⑤9},但从行政专长角度来看也有一定的合理性^{⑥0}:现代社会中行政机关制定的规范性文件仅就数量而言已经远超立法机关的立法,相比法院,行政机关显然更熟悉自己制定的规则,对不同的解释所导致的政策性后果也可以有更好的判断。

2. 正当程序

我国现行立法对答复类行政解释的作出程序并无统一规定,实务中由各行政机关裁量决定。在行政解释的司法审查过程中,如查明答复类行政解释曾经征求过公众或专家意见、经过审慎合议、向公众公开等有助于提升其解释正当性的程序的,法院应相应地增加对其尊重程度。如此处理,从效果上应可激励行政机关在作出行政解释时更多采取征求意见、多方审议和信息公开等程序。

但这不应被误解为,应从规范上强制要求所有答复类行政解释的作出均须经过征求意见、审议、公开等程序。因为这些程序固然有提升行政解释可接受性的收益,但却以牺牲行政的灵活性和便利性为代价。事实上,已有学者指出“程序强化”可能令“行政僵化”之“隐忧”。^{⑥1}从行政程序设置的原理上来看,答复类行政解释正是以灵活便利见长^{⑥2},如能恪守“解释”的原本界限,不在被解释的实在法规范之外减损权利或新增义务,

⑤8 参见金自宁:《科技专业性行政行为的司法审查——基于环境影响评价审批诉讼的考察》,载《法商研究》2020年第3期,第154-168页。

⑤9 参见前注⑤0,张志铭文,第113-114页。

⑥0 See Cass R. Sunstein & Adrian Vermeule, *The Unbearable Rightness of Auer*, *The University of Chicago Law Review*, Vol.84:297, p.297-322 (2017).

⑥1 参见戴加佳、宋华琳:《行政规范性文件司法审查的要素分析》,载《新视野》2020年第2期,第88-94页。

⑥2 See William R. Andersen, *Informal Agency Advice — Graphing the Critical Analysis*, *Administrative Law Review*, Vol.54:595, p.595-609 (2002).

则并无必要一刀切地将征求意见等作为强制性程序要求。

基于正当程序的精神,中立无偏私的解释应得到更多的尊重。对于涉嫌被诉讼当事人策略性地运用以获得个案胜诉结果的行政解释,应当予以严格审查。就此而言,从解释的时点来看,在诉讼进行过程中专为诉讼而制作的答复类行政解释的分量应低于在诉讼之前即已存在的答复类行政解释;从发出解释请求者来看,法院请求解释而得到的答复的分量则应重于诉讼当事人发出解释请求而得到的答复的分量。理由是:诉讼当事人在诉讼进行过程中请求行政机关解释,通常难免存在为自己胜诉寻求支持的动机。

从行政诉讼监督行政的法定功能来看,与原告提交的有利于公民、法人和其他组织的答复类行政解释相比,司法机关对于被告提交的有利于行政主体方的答复类行政解释的审查应当更为严格。其中,需要警惕的是,上级行政机关在行政诉讼过程中应被告请求所作答复,不论实质合理与否,这种答复在程序正当性上是比较可疑的。出于类似的考虑,行政诉讼中对行政解释的审查整体上应当严于民事诉讼和刑事诉讼。在民事诉讼和刑事诉讼中,作出解释的行政机关通常并非诉讼结果的“利害关系人”,而在行政诉讼中,解释者和被告同属行政机关,需要额外努力以免去“官官相卫”的嫌疑。就此而言,法院在行政诉讼中主动致函行政机关所获得的解答,也应予以较为严格的审查。理由是:尽管法院主动获取的行政解释,多半会落入行政专长领域,但若放松甚至放弃对这类行政解释的审查,行政诉讼监督行政的法定功能就会被削弱甚至被架空。

3. 解释理由

法院对行政解释的审查不应仅以合法性为限,也当及于合理性。对行政解释的司法尊让(judicial deference),已经因美国著名判例“谢弗林案”而获得行政法学界广泛关注和强调;而从“谢弗林案”案情来看,这种司法尊让以案涉行政解释“合理”为前提^⑧。由此,答复类行政解释如给出适当、充分、易于理解的理由的,在法院认定其说服力时,应加重其分量,否则应减轻之。这对于包括但不限于答复类行政解释的全部行政解释之司法审查都是成立的。

与正当程序考量因素类似,就答复类行政解释的审查而言,出于保留行政自主性和灵活性的考虑,是否列明解释理由及理由是否充分,作为认定说服力的考量因素,只应被理解为对行政机关的激励,不应被理解为强制要求行政机关在全部种类的行政解释中都列明理由。事实上,我国现行实在法也并不要求行政机关在所有形式的行政解释中都提供作出特定解释的理由。比起一刀切地要求以灵活便利见长的答复类行政解释在作出时即全面详细地说明理由,更好的选择是将是否在制作时说明理由交给行政主体根据解释所涉问题的疑难复杂程度、影响范围等酌情裁量。

观察我国行政诉讼实践,的确有一些行政函件同时提供了作出特定解释的理由。如,在“画木木公司案”中,生态环境部复函中解释了为何木柴亦可视为高污染生物质燃料,即“直接燃用的生物质燃料(树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等)和生物质成型燃料

^⑧ 参见高秦伟:《政策形成与司法审查——美国谢弗林案之启示》,载《浙江学刊》2006年第6期,第142-149页。

在组分上没有区别,非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质燃料参照《高污染燃料目录》(国环规大气〔2017〕2号)中关于生物质成型燃料有关规定执行”。但是,实践中大多数答复类行政解释并没有明确给出理由或给出的理由不完整或缺乏针对性,这种答复类行政解释,若在诉讼中成为争点,诉讼当事人和法官均可致函行政机关要求其作出进一步说明。如行政机关在回应中提供了适当、充分理由的,法院在认定案涉行政解释的说服力时,也应加重其分量。

(三) 综合权衡与判断

对答复类行政解释进行审查,需要注意标准与考虑因素的不同。其中,合法性是标准,据之作审查结果指向满足或不满足这些标准的判断,一旦得出不满足此标准的判断,该解释就被排除;正当程序和解释理由等是应予权衡的考虑因素,具备这些因素,只是加重了其分量,若不具备这些因素,也只是减轻了其分量,并不一定意味着应当排除该答复类行政解释。

根据考虑因素权衡轻重当然难免进入非白非黑的灰色地带。如,行政机关在行政诉讼过程中提供的答复类行政解释,从正当程序因素看,需要警惕,但从行政专长和解释理由等因素看,可能又值得尊重。最后赋予此解释多大分量,只能是综合权衡的结果。

依标准的判断也并不总是黑白分明的。如,判断答复类行政解释内容是否违法、是否越过法律解释应然界限而成为新的“立法”,在实践中有时就并不容易,特别是在涉及对被解释之法律条文作“扩大”或“限缩”解释、甚至“法律续造”以填补法律漏洞时^④。

以“罗文斌案”为例。《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定,“单纯混合、分装”的化肥生产项目应当制作环境影响报告表,而诉讼当事人双方都同意案涉项目的热源涉及化学反应,分歧在于:原审原告以该化学反应的存在为由认定案涉项目不再是“单纯”混合混装,故不再适用该项规定;而原审被告环评审批机关则认为案涉项目在热源供应之外的“生产”过程仍然是“单纯混合、分装”,故仍在该项规定适用范围内。原审法院在判决中支持了行政机关的解释。但是,这一将供热与主要生产过程分离、将“生产”理解为“主要生产过程的”“限缩”解释,是否比原审原告的解释更为妥切?还是已经超出了“解释”的界限,改变了法条的意义呢?仅凭法条文字本身,很难得出确定的答案。这种疑问也并不会因为终审判决的作出而消失,此案中原审原告的确在二审判决生效之后又提出申诉,请求再审,并提交了原环保部复函以支持己方解释^⑤。

上述困难的存在,事实上也提示着诉讼过程中当事人辩论程序的重要性。给双方当事人相互辩驳的机会,不仅是程序正义的要求,也有助于法官从多方面获得信息,以便对行政解释展开相对深入的审查。

④ 参见前注⑤,托马斯·M.J.默勒斯书,第363-397页。

⑤ 再审法院以不相关为由未采纳该复函,并事实上回避了再次论述“单纯混合、分装”究竟应否限缩解释的难题。

五、结 语

立足于司法实践的需要,我国现行行政诉讼制度区分了具体行政行为的审查和抽象行政行为的审查,而答复类行政解释无法纳入这两种审查中的任一种。一方面,答复类行政解释独立于具体行政决定而存在,针对具体行政行为展开的审查对其力有不逮;另一方面,如将之视同抽象解释并适用抽象行政行为的审查(在我国目前主要指行政诉讼法上的规范性文件附带审查),又会失之过苛。由此,将答复类行政解释单列出来展开研究实有必要。

在作为动态过程的诉讼活动中,法院是包括答复类行政解释在内的各种诉讼材料之应用的最终控制者。司法实践中对答复类行政解释处理不一的做法值得关注 and 改变,应当保障当事人对答复类行政解释提出异议的机会,法院应在对答复类行政解释实施审查的前提下,认定其合法性和说服力。其中合法性,主要涉及解释主体权限和解释本身的实质内容;而答复类行政解释之说服力认定,需全面考量解释者的制度角色(行政专长)、解释程序(解释的请求者/提交者、请求解释的时点、解释本身的制作程序)以及解释理由等因素。

行政解释的法律规制是公法学的经典议题之一。笔者并不单单从理论出发进行研究,而是选择面向真实世界中的现实问题,集中关注已经大量进入诉讼实践的答复类行政解释之司法应用问题。从既有研究更关注抽象行政解释的现状来看,不从实践出发很难特别关照到答复类行政解释介于抽象与具体之间的“另类”特性。举例来说,解释性规则与立法性规则的区分,以及由此延伸开来的行政规则篡夺立法权的问题,被较多学者放在重要地位^{⑥6},但这些既有讨论对于本文的研究而言并不切题,因为这一区分本身是对以规范性文件为存在方式的“规则”的区分。

在我国诉讼实践中,答复类行政解释与个案解释的区别较为明显,对此毋庸赘言。就答复类行政解释与抽象解释的区分,则需要补充说明一点,即对答复类解释与抽象解释的区别亦不可作绝对化的理解:无论解释请求的发出者是法院、下级行政机关、还是公民、法人或其他组织,作为解释者的行政主体,若认为特定解释内容具有典型代表性,为统一执法考虑,有意使答复类行政解释的共通部分具有反复适用的一般效力的话,完全可以通过将解释中的共通内容抽离出个案情境,并经法定的制作程序在拟适用的范围内予以公布,从而将其转化为抽象形式的解释^{⑥7}。我国行政实践中,有一些行政解释就处于这种“转化”的中间状态:行政机关在答复特定的解释请求时,有时会“抄送”其他下级行政机关,而这通常被理解为解释者有意使其解释在更大范围内得到遵照执行,当被

^{⑥6} See Richard J. Pierce, *Distinguishing Legislative Rules from Interpretative Rules*, *Administrative Law Review*, Vol.52:547, p.547-574 (2000).

^{⑥7} 参见蔡茂寅:《函释的法律性质》,载《月旦法学杂志》2001年第74期,第24-25页。

抄送的下级行政机关照此办理时,该解释就比那些直接回复请求者而未“抄送”的解释得到了更普遍的适用。

最后,需要补充说明的是,笔者集中关注诉讼过程中的答复类行政解释,试图解决在司法这一末端,如何处理已经存在的、形形色色的答复类行政解释。而在实践中,有大量合法性和正当性存疑的答复类行政解释,并未进入诉讼过程,它们同样有如何规范的问题。司法程序显然并非规范答复类行政解释的唯一途径,其他如行政机关内部控制和立法机关的监督等同样可以发挥作用,对此将于另文探讨。

Abstract: Administrative letters as legal interpretation are different from both abstract and concrete administration act. Hence, it is difficult to include them into China's existing system of judicial review. The judicial practices dealing with them have been inconsistent. Administrative letters as legal interpretation are about legal issues instead of factual issues, and thus they should not be listed as 'evidence'. At the same time, categorizing them as the 'basis' would not be in accord with our positive law. Given administrative letters have significant *de facto* impact on judicial decisions, it won't be fair that litigants have no chance to express their dissent. Both the legality and persuasiveness of administrative letters as legal interpretation shall be determined in the process of review.

(责任编辑:王莉萍)